

个人信息监管沙箱的法理基础 与制度构建

崔聪聪

(北京邮电大学法律系 北京 100876)

内容提要:以个人信息为主要内容的大数据是数字经济的核心生产要素。目前,个人信息行政监管的主要手段是专项治理。个人信息专项执法所依赖的自上而下控制型监管路径,导致监管与创新之间冲突,甚至出现监管抑制技术创新等诸多问题。个人信息专项治理的重点是超范围收集、强制索权和一揽子授权等违法处理行为,虽然可以防控个人信息大规模处理引发的泄露和被滥用风险,但是对数字经济发展形成了制度性约束,势必会造成数据资源的结构性浪费和紧缺。通过专项整治防控个人信息处理风险,凸显了运动式监管范式的困境。个人信息行政监管,亟待形成一种适应数字经济发展的系统性范式。基于监管合作主义、穿透式监管策略和监管试验主义的个人信息监管沙箱,是诱发个人信息行政监管范式转换的关键变量,可以有效平衡数字经济发展和个人信息安全之间的冲突,应当作为未来个人信息的监管工具。

关键词:个人信息监管沙箱 数字经济 穿透式监管 合作式监管

DOI:10.16092/j.cnki.1001-618x.2024.02.001

一、问题的提出

数字时代,技术创新、数据流通复用,以及个人信息滥用叠加引发的个人信息安全危机对现行个人信息监管模式、理论逻辑和法律制度提出了全面挑战。《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》)生效后,国家网信办、工业和信息化部、公安部、市场监督管理总局以及地方网信、工业和信息化、公安和市场监督管理部门纷纷开展个人信息专项治理

作者简介:崔聪聪(1978—),男,汉族,河北深州人,北京邮电大学法律系副教授。

本文为国家社科基金重大项目“网络空间政策法规的翻译、研究与数据库建设”(项目编号:20&ZD179)的阶段性研究成果。

活动,个人信息专项执法取得了一定效果。但是个人信息执法所依赖的自上而下控制型监管路径,造成监管者与被监管者之间对立、监管影响甚至抑制技术创新等诸多问题。现行个人信息监管机制,事后监管模式应对个人信息滥用引发的风险乏力,压缩收集范围在一定程度上遏制了技术创新甚至影响数字经济发展,亟须突破传统监管维度,探索契合数字经济发展规律的监管手段,解决个人信息监管“治乱循环”的桎梏,实现个人信息处理安全可控,为铸造数字经济新优势提供新的动能。监管沙箱概念起源于金融服务业,^①后拓展至个人信息保护领域。^②个人信息监管沙箱是监管机构设置的一个相对隔离的真实测试环境,用于测试,发现互联网产品或者服务的个人信息处理过程中不符合个人信息保护法律法规的功能设计以及潜在的风险,并据此对产品或者服务的设计进行调整、修正,以降低或者消除个人信息处理风险的措施。^③旨在通过试验性的方式防控个人信息处理过程中的风险、平衡安全与利用冲突的个人信息监管沙箱,为重塑个人信息监管理念和路径提供了新的思考理路。

二、引入个人信息监管沙箱破解监管困境

当前,我国个人信息治理仍沿用“命令—控制型”治理路径,即授予国家机关制定、执行监管规则,并对违反该规则的行为予以制裁。“命令—控制型”的“运动式”执法无法应对个人信息处理的隐蔽性和技术难题,以压缩个人信息处理范围的监管措施压制了数据资源的有效供给。个人信息治理有必要引入个人信息监管沙箱,探索契合数字时代数据高速流通复用需求的监管进路,为构建个人信息长效治理机制奠定基础。

(一) 个人信息治理的结构性缺陷

监管机构针对超范围收集、强制索权、一揽子授权开展了系列专项治理行动。“运动式”执法面临着横向和纵向两个维度上的危机:一是个人信息违法违规的新手段、新方式层出不穷对执法能力提出的挑战,个人信息“普遍性违法”态势导致执法资源严重不足;二是看守式监管对数字经济发展形成了制度性约束。

1. 运动式执法影响长效治理机制建立。个人信息保护专项整治活动已成为一种常态。2019年1月,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、市场监督管理总局开展App违法违规收集使用个人信息专项治理。2021年,工业和信息化部全年组织对208万款App进行技术检测,通报违规App 1549款,下架514款。2022年4月21日,国家邮政局、公安部、国家互联网信息办公室联合部署开展为期半年的邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。^④2023年,工业和信息化部累计通报8批侵害用户权益行为的App(SDK)。除中央部委的专项整治行动外,天津、河北、浙江、北京等地方网信办、公安局、市场监督管理委、通信管理局,相继开展了

① 从本质上看,监管沙箱就是监管者为促进金融创新、降低风险并保护金融消费者而创建的一个监管框架(regulatory framework)。参见张红:《监管沙盒及与我国行政法体系的兼容》,载《浙江学刊》2018年第1期。

② 未来,可能不仅在金融监管领域设计监管沙箱模式,各行各业都可推出与金融监管沙箱理念相似的沙箱。参见黄震、张夏明:《监管沙盒的国际探索进展与中国引进优化研究》,载《金融监管研究》2018年第4期。

③ 崔聪聪:《个人信息保护的行政监管及展开》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2022年第5期。

④ 国家邮政局、公安部、国家互联网信息办公室联合启动邮政快递领域个人信息安全治理专项行动,
http://www.gov.cn/xinwen/2022-04/23/content_5686824.htm,访问日期:2024年2月3日。

App 个人信息安全专项治理行动。

个人信息保护的“专项行动”“专项整治”“专项执法”“专项通报”提升了个人信息处理者的合规意识,广大网民关注的超范围收集、强制索权、一揽子授权等问题有所改善,因个人信息泄露引发的电话骚扰、网络诈骗等乱象得到有效治理。但是,“运动式”执法只能取得短期治理效果,长期形成的路径依赖有碍于个人信息长效治理机制形成。“运动式”监管会助长个人信息处理者的侥幸投机心理,违法违规收集和使用个人信息在专项执法行动结束后会死灰复燃。为应对专项治理行动,个人信息处理者采取各种形式逃避监管:加密传输个人信息、代码加壳等方式逃避技术检测,仅设置形式意义上的“关闭定向推送按钮”而非调整定向推送的参数以满足关闭定向推送功能要求而进行技术对抗。“运动式”监管路径暴露出个人信息保护部门缺乏对监管体系和治理机制的宏观思考,深层次的原因是个人信息行政监管延续传统监管理念而缺少一个适应数字经济发展的理论框架。^⑤

2. 看守式监管引发监管窒息、对立。除“运动式”执法外,现行个人信息保护行政监管仍沿用“命令—控制型”监管手段。“命令—控制型”产生的监管刚性无法顾及个人信息处理者的产品或者服务的特殊性,其结果是个人信息处理者合规边际成本的增加,有可能导致以个人信息作为主要营利手段的互联网行业全面萎缩。例如,现行监管要求将适用于收集的最小必要原则扩展至个人信息收集、使用、对外提供的整个处理环节,并要求所有行业领域的个人信息处理者遵守该原则,因未考虑以数据分析为业等个人信息处理者的正当需求,致使专业数据分析机构在开展业务过程中遇到“原料供应不足”的困境。“一刀切”式的强监管导致了监管窒息,妨碍了技术创新进而影响数字经济的活力。

“命令—控制型”的个人信息监管规则容易产生监管套利。^⑥ 个人信息处理规则的高度抽象性以及概念内涵的模糊性、概念外延的非周延性,使个人信息处理行为出现“貌合神离”的结果:个人信息处理者仅注重个人信息收集前端和形式方面的合规建设,忽视个人信息存储利用过程中的安全保障义务,个人信息面临巨大的被泄露和被滥用风险。监管套利反映了个人信息处理者与监管机构在个人信息收集范围、利用深度、安全保障等方面的冲突,个人信息处理者对个人信息的无限需求、深度利用以及适度安全的诉求显然无法契合监管的最小必要原则以及近乎绝对安全的要求。

“命令—控制型”的监管方式的实质是法律父爱主义在网络空间的延伸。若对其实践适应性问题不加以认真审视,则可能沦为耗资巨大而收效甚微的“屠龙术”。^⑦ 如果立法和执法只是简单地施加各种强制性外部要求,个人信息处理者只能是被动地应付法律规定的保护义务甚至规避监管,没有充分的动力和能力去保护个人信息。“挤压式”执法有可能引起反向激励效果,个人信息处理者的被动合规可能引发更大的社会风险。不考虑数据生产的特点而简单地采取“命令—控制型”的监管方式会使监管者与个人信息处理者之间产生对立。对立引发的信

⑤ 参见吴烨:《金融科技监管范式:一个合作主义新视角》,载《社会科学》2019年第11期。

⑥ 参见周仲飞、李敬伟:《金融科技背景下金融监管范式的转变》,载《法学研究》2018年第5期。

⑦ 参见姜方炳:《制度嵌入与技术规训:实名制作为网络治理术及其限度》,载《浙江社会科学》2014年第8期。

息交流不畅进而造成信息不对称会导致监管部门采用更加严厉的监管方式来防控个人信息处理的风险,其结果是再度激化对立而影响数字经济的健康发展。

3. 执法资源约束导致个人信息监管失灵。个人信息处理的技术性、隐蔽性,使自上而下的“命令式”监管范式失效。^⑧ 因执法资源有限,个人信息专项治理行动只能聚焦头部 App,难以全面覆盖国内近两百万的 App 运营者。科技创新加大了监管者和被监管者之间的信息不对称程度,监管者缺乏充分的技术手段进行数据触达。^⑨ 个人信息处理往往在后台进行,监管机构和个人信息主体难以了解具体的处理过程,特别是缺乏技术手段获取个人信息后台分析、利用与共享的可靠信息,因此难以监管和约束个人信息处理者的后台处理行为,导致个人信息风险具有隐蔽性;个人信息处理者不同业务之间相互关联、渗透使得个人信息在不同业务线之间以及不同的个人信息处理者之间频繁共享,导致个人信息处理风险波及面广,甚至出现类似金融风险的传染性特征,特别是不同应用服务共用同一账号、密码,发生个人信息泄露事件后产生的叠加与聚合效应,导致其破坏性更强。

当前,个人信息监管模式为静态监管和事后监管,此种规制方式需事先制定行为规则,要求监管对象遵从这些规则。^⑩ 静态监管和事后监管难以跟上数字技术和个人信息处理方式变革的步伐,也难以预料互联网商业模式和数字应用的变化。个人信息处理行为和方式高度动态、易变的特性使得事先制定的规则可能滞后于实践。就违法处理个人信息而言,从违法收集身份证号码、健康信息到现在的违法处理人脸信息、精确位置信息、智能终端设备安装的应用列表,以及违法读取剪切板信息等。近期出现的 App 未经用户允许利用设备传感器信息自动启动开屏广告,因设备传感器信息是否属于个人信息存在争议,导致上述个人信息处理行为处于“灰色”地带,对个人信息执法提出了严峻挑战。

(二) 个人信息治理理念出现偏差

现行个人信息监管范式对个人信息用途和功能变化明显“水土不服”。数字时代,个人信息的功能不再是简单的识别个人身份和认证功能,而是数字经济的重要生产资料。个人信息流通和利用的需求,要求个人信息监管应遵循适应性监管原则。适应性监管原则是指监管措施和监管方式的选择应因监管对象、监管环境、现实条件的不同而有所差异,它要求监管原则和监管方法应随机而变,原则不能僵化,方法不能单一,不能搞“一刀切”。^⑪

1. 绝对安全理念。数字经济发展对个人信息的需求使个人信息功能发生了深刻变化:互联网发展的早期,个人信息的主要功能是用用户身份认证;数字时代,个人信息被广泛用于分析用户特征和行为规律。数字技术使观察、记录乃至监控个体的日常行为以及分析个体的倾向、偏好成为可能,而且比之前更加容易、迅速、隐蔽。每一起严重的网络暴力事件背后,往往都是组织者通过个体搜索记录、浏览记录以及在社交媒体上发布的信息筛选跟帖人、转发者,通过智能推送将本无意思联络的碎片化网络侮辱、诋毁、诽谤“勾连”起来,产生巨大的杀伤力,造成

⑧ 崔聪聪:《个人信息的内生安全机制及其实现》,载《东方法学》2024年第1期。

⑨ 杨东:《监管科技:金融科技的监管挑战与维度建构》,载《中国社会科学》2018年第5期。

⑩ 杨松、张永亮:《金融科技监管的路径转换与中国选择》,载《法学》2017年第8期。

⑪ 张永亮:《金融监管科技之法制化路径》,载《法商研究》2019年第3期。

被害人“社会性死亡”甚至精神失常、自残、自杀。继大数据杀熟、平台利用算法工具盘剥骑手之后,个人信息又成为网络暴力的“助推器”。

从网络技术到大数据,不仅改变了个人信息处理的模式与形态,更深刻地改变了背后的风险逻辑:互联网发展的早期,个人信息的功能单一、共享不频繁,风险主要是因个人信息泄露引发的对个体的侵扰等,个人信息保护的要求是最大限度地防止泄露等。数字时代,个人信息的深度利用、频繁共享以及数据交易流通,个人信息的主要风险源由数据泄露转为个人信息深度挖掘利用引发的个体被不当影响甚至被操控的风险。超范围收集与滥用行为叠加,风险不再是信息的泄露,而是通过算法等底层技术获得极强的预知性,并以此预知来限制、禁止或选择性漠视个人的某些权利,或者怂恿、引诱、误导个人实施某些非法行为。^⑫在个人信息功能和利用场景发生深刻变化的情况下,现行个人信息保护行政监管仍沿用传统的监管思维和模式,即拒绝接受风险的理念、有风险就要消除的绝对安全观,显然无法找到安全与发展的契合点。

2. 基于事件治理。在中国网络治理实践中,网络事件通常被视为社会秩序的主要威胁,从而形成了一种“以事件为中心”的治理模式。^⑬“以事件为中心”的网络治理模式是围绕网络事件的防范、控制、转化、平息事态和消除影响以及后续法律的立、改、废等系列要求设计的治理机制。“运动式”执法源于“以事件为中心”的治理思维,引发“运动式”执法的事件包括法律的通过以及发生引发舆论关注的典型事件,前者如《个人信息保护法》施行,后者如“徐玉玉事件”、媒体披露的大数据杀熟等事件。“以事件为中心”的治理模式虽然能够及时回应网民和政府关注的个人信息违法处理的重点和突出问题,但是被动的事后回应型的治理方式无法适应个人信息处理普遍性违法的问题。

“以事件为中心”的治理模式没有抓住主要矛盾和要害问题,存在比较严重的背本趋末。当代社会风险常以技术载体的方式呈现,或由技术的不确定性引发,故而防控风险需依靠政策的完备与制度的建构。^⑭个人信息深度挖掘、高速流通复用衍生出众多社会风险,“以事件为中心”的治理措施无法形成个人信息的长效治理机制,无法应对数据大规模泄露引发个人人身和财产安全风险以及算法滥用引发的人格异化危机。基于对风险的焦虑,个人信息主体不愿意提供更多的信息,在个人信息处理者征求个人同意时,个人信息主体选择拒绝或者尽可能少的授权,甚至提交非真实信息以规避数据泄露、数据滥用的风险。缺乏信任除影响个人信息主体提供和披露其个人信息的积极性外,也成为个人信息处理者之间共享数据的障碍。个人信息监管,亟待形成一种面向“创新”的系统性范式。

3. 误读个人信息权益。现行“命令—控制型”监管范式的理论基础是保障个人信息主体的控制权:个人信息之于个人信息主体是一种支配性利益,为保障个人信息主体的支配性利益,需要赋予个人信息控制权,监管的目的是保障个人信息主体实现控制权。网络发展初期,个人信息的收集方式多为用户提交给个人信息处理者,个人信息主体可以自主决定是否提交个人

⑫ 鲁传颖、张璐瑶:《人工智能的安全风险及治理模式探索》,载《国家安全研究》2022年第4期。

⑬ 张兆曙:《以事件为中心:中国网络治理的基本模式》,载《浙江学刊》2019年第3期。

⑭ 徐亚清、于水、姜凯宜:《新时代网络治理的历史缘起与话语转向》,载《中共中央党校(国家行政学院)学报》2019年第2期。

信息或者提交个人信息范围。个人信息控制理论自然延伸至“知情”“同意”原则。“知情”“同意”原则的核心要义是每个人都应该对自己的个人信息保持完全控制,未经个人同意,个人信息处理者不得处理其个人信息。换言之,法律推定每个人都有对其个人信息完全控制的利益,这种利益在任何情况下都应受到法律保护。

个人信息的本质属性是社会性,个人信息使处于社会环境中的主体能够在既存的文化和社会矩阵中导航。^⑮如果目标是让每个人都能完全控制自己的个人信息,那么个人信息的流动就会受限,个人信息有序流动产生的价值也就无从谈起。沿着个人信息的社会性这一主线,个人信息主体对个人信息的利益并非支配性利益而是防御性利益,^⑯监管目标也应当从个人信息控制转为防止个人信息遭受损害。在数据资源开发过程中,数据处理者往往需要综合利用个体的行为信息、身份信息支撑业务开展、优化产品功能,以压缩个人信息处理范围为主要手段的强监管导致可合法使用的数据资源尤为稀缺。构建个人信息公平利用秩序,平衡利用和安全之间的矛盾,不能依赖由“个人控制支配”个人信息,通过“命令—控制型”监管保障个人对信息的支配控制。鉴于此,国家应当在事前以积极主动的形式介入个人信息处理。

(三) 通过监管沙箱重塑个人信息监管机制

风险的“泛在化”是网络社会的固有特点,技术的不确定性客观上增加了风险产生的概率。^⑰在这种情况下,基于“风险排除”或者“绝对安全”的传统保障理念将遭遇前所未有的困境。个人信息监管既要防止“命令—控制型”监管引发的扼杀活力、阻碍创新的结果,又要防止自由放任的监管立场引发的个人信息野蛮处理,放大其破坏性并外溢引发社会风险。通过个人信息监管沙箱降低监管成本、提升治理效果,为技术创新留足必要空间,保障数字经济持续健康发展。

1. 为技术创新留足必要空间。在数字时代,每个国家和政府都在努力追求以风险最小化的方式进行数字化变革,这意味着应当在以负责任的方式处理个人信息和保护个人信息主体合法权益的同时,实现以数据为主导的创新。为实现上述目标,立法部门、监管机构、个人信息处理者、相关行业组织以及个人信息主体都面临着挑战,因为个人信息合规性越来越被视为一个迭代和快速并伴随反馈循环和改进的过程。个人信息监管机构可以通过监管沙箱及时获得有关前沿研究、开发以及技术发展方向动态,为将来立法提供实践支撑和参考。个人信息处理者可以在真实的市场环境中开发突破性产品、服务,保证在实验、测试阶段不会违反法律法规和监管要求,降低产品或者服务因违法被下架或者停止服务的损失;在产品或者服务上线后及时调整、修改功能,保证产品或者服务合规。

个人信息监管沙箱可以解决互联网产业发展过程中两个无法避免的不确定性:创新的不确定性和过于原则的个人信息保护法律条文引发的不确定性,使个人信息处理者特别是科技初创企业在不危害个人信息权益的情况下开发和测试其产品和服务。为了确保技术创新者享受到监管沙箱的真正好处,个人信息监管机构需要考虑参与者在沙箱中测试其产品或者服务

^⑮ Julie E. Cohen: Symposium, What Privacy is For, 126 HARV. L. REV., 2013.

^⑯ 王锡铨:《国家保护视野中的个人信息权利束》,载《中国社会科学》2021年第11期。

^⑰ 马宁:《国家网络安全审查制度的保障功能及其实现路径》,载《环球法律评论》2016年第5期。

时可以获得相对宽松的监管执法。以人脸信息处理为例,逐一获得用户的单独同意徒增大量的成本,对防控人脸信息泄露、被滥用等亦无实益。在个人信息监管沙箱环境中,个人信息处理者使用人脸信息进行产品优化、训练算法时,在履行防止人脸信息泄露等安全保障义务的基础上,可以不必征得个人信息主体的单独同意,个人信息处理者可以降低大量的谈判成本,免于无法获得个人信息主体有效同意阻碍产品开发的危险。

2. 降低监管成本。个人信息挖掘分析导致的隐私泄露损害往往具有无感性,个体很难通过诉讼等方式获得救济,因此隐私泄露的成本通常由用户承担。物理空间的违法行为往往是单个的、偶发的,即便是共同违法行为或者群体性事件,也不会造成大量的人遭受侵害。个人信息违法处理往往具有普遍性,如用户必须提供人脸信息才能使用某移动互联网应用程序的购物功能,此时受害人涉及使用该移动互联网应用程序的所有用户,这些用户动辄几千万甚至几个亿。个人信息不仅影响个体利益,当侵犯个人信息权益的行为达到一定规模和程度时,整个社会秩序都会受到冲击。为应对个人信息处理者的普遍性违法行为,国家不断加大投入个人信息监管资源,但仍然无法有效遏制个人信息违法处理行为高发的态势。

个人信息监管沙箱确保创新以负责任的方式进行,减少规制创新的成本,有利于提升社会效益。网络社会高度复杂,人们不可能总是事先依照既定的规范或者固有的自然概念,来确定他的行为是否正确。^⑮ 监管沙箱为监管机构提供了利用信息反馈机制整合规则制定中动态因素的机会,使规则适应那些可以确定的未来变化情况。^⑯ 数字经济发展进一步放大了个人信息监管权不对称性、监管规则滞后性等负面效应,而监管沙箱可以有效控制此类负面影响。监管者充分了解个人信息的具体操作细节、内含的风险,为监管者进一步制定政策积累经验。监管沙箱让监管机构在个人信息处理者的产品或者服务上线之前就有机会了解潜在的风险,从而提前进行沟通协调,降低了事后监管成本。^⑰

3. 提升治理效果。数字时代,个人信息保护不能一味地强调控制、权利、安全,而应当通过具体的制度设计和执法将个人信息处理风险控制在一定范围内从而实现保护个人信息所承载的各种利益的目的。既然数据问题由互联网工具系统引发,则解决之道也应存在于数据工具系统中。^⑱ 通过设立相对隔离的测试系统,个人信息收集、存储、挖掘分析、对外提供、出境、删除和销毁以及匿名化、去标识化等在真实的环境中进行测试,通过测试发现违法处理以及个人信息泄露、个人信息利用对个体自主性、隐私权等合法权益的可能危害,并据此对产品或者服务的设计进行调整、修正、优化,以降低或者消除个人信息处理风险的措施。个人信息监管沙箱创造的信息交流和沟通机制,使监管部门和个人信息处理者之间的信息交换实现了从被动

⑮ 张永亮:《金融科技监管的原则立场、模式选择与法制革新》,载《法学评论》2020年第5期。

⑯ Wulf A. Kaal: Dynamic Regulation Via Governmental Contracts, University of St. Thomas (Minnesota) Legal Studies Research Paper, 2015.

⑰ 张红:《监管沙盒及与我国行政法体系的兼容》,载《浙江学刊》2018年第1期。

⑱ 梅夏英:《在分享和控制之间——数据保护的私法局限和公共秩序构建》,载《中外法学》2019年第4期,第867页。

到主动、堵塞到畅通、强制到自愿的变迁,进而达到缓解信息不对称、平衡风险与创新的良好效果。^②

监管沙箱并非豁免个人信息处理者的法定义务,而是在数字技术创新所导致的个人信息处理风险日益加剧的情况下,在保障个人信息法律规则基本稳定的基础上,正视个人信息处理者因业务开展、服务优化、风险控制等收集、使用个人信息的合理诉求,赋予个人信息监管机构在制定和实施个人信息监管规则方面享有更大的自主权,探索能够适应数字经济运行规律的监管手段和措施。此外,个人信息监管沙箱亦鼓励个人信息处理者制定更加严格的合规要求和安全保障标准,并将其内嵌于业务和产品中。之所以如此,是因为个人信息处理规则无论如何精细也脱离不了“一刀切”的弊端,其无法充分顾及不同个人信息处理者的收集方式和类型、使用场景和风险、安全保障能力和措施的差异性,为防止监管真空,可以通过个人信息处理者的风险管理来弥补监管机构的监管不足。^③

三、个人信息监管沙箱的理论表达

数字时代,个人信息处理行为多样化、频率高以及深度挖掘和分析,使安全风险变得更加复杂,传统的监管方式无法有效地应对新出现的风险和挑战。个人信息监管沙箱除提供有效的合规和监管工具之外,更重要的是成为推动个人信息监管范式转变话题讨论的关键因素。个人信息监管沙箱代表了个人信息监管的下一个逻辑演进,并将发展成为支撑整个数字时代个人信息监管体系构建的基础要素。

(一) 监管合作主义

合作监管是在合作治理的大背景之下,在规制领域的一种变革主张。^④万物互联时代,数字技术创新将人类社会牵引至一个高度复杂且具不确定性的时代,只有个人信息处理者、行业组织、监管部门等多元社会治理主体在合作的意愿下进行合作式治理,才能有效解决风险社会的各种问题。合作主义,作为监管者和被监管者协同应对个人信息处理风险的监管哲学,履行个人信息保护职责的部门不仅是个人信息处理秩序的守护者,更是个人信息合规的引导者和协调者;个人信息处理者不仅是服从者,更是监管部门的合作者。^⑤数据生产要素化、数据高速流通复用需要一种可以激发个人信息处理者从“被动合规”走向“主动合规”的监管范式,制止个人信息处理者“逃逸监管”的冲动,调动个人信息处理者主动采取措施防控个人信息处理风险的积极性,共建个人信息处理秩序。“共建”要求在消除对立的前提下迈向合作共同探索、寻找合规的最佳方案。

个人信息保护工作部门与个人信息处理者并非完全对立的关系,而是具有共同的治理目标,即防范个人信息处理引发的社会风险。个人信息监管沙箱作为合作主义监管范式的一种实践探索,是基于监管部门对个人信息处理者的“有限度信任”的试错监管机制,通过搭建监管

② 刘志云、刘盛:《金融科技法律规制的创新——监管沙盒的发展趋势及本土化思考》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2019年第2期。

③ 参见周仲飞、李敬伟:《金融科技背景下金融监管范式的转变》,载《法学研究》2018年第5期。

④ 张红:《监管沙盒及与我国行政法体系的兼容》,载《浙江学刊》2018年第1期。

⑤ 参见吴烨:《金融科技监管范式:一个合作主义新视角》,载《社会科学》2019年第11期。

部门与个人信息处理者之间的沟通路径,构建企业产品和服务创新的“安全港”,在监管部门的指导下企业整改在监管沙箱中暴露的问题。监管机构与个人信息处理者同时在线,现场“联合办公”,共同发现和解决个人信息处理过程中的问题。监管与创新协调共进的监管沙箱能有效避免“摆钟式”监管,为个人信息处理者提供较稳定、可预期的动态监管指引。^{②6}

通过与行业内部及其行业间的合作与信息共享,个人信息监管部门可以充分利用行业的智慧,探索有效的风险治理框架。在广泛用途的监管沙箱中与行业成员积极接触和合作,个人信息监管机构和个人信息处理者、行业组织共同探索治理算法歧视、个人信息泄露、个人信息滥用的风险以及有效的应对方法。在合作主义进路下,个人信息监管部门的角色由“划桨”变为“掌舵”,旨在弥补“市场失灵”和“监管失灵”。就监管手段而言,合作主义并非简单粗暴地合并相互冲突的利益关系,而是在承认“命令—控制型”监管模式的局限性的前提下,通过系统化整合相关制度,构建技术机制连接监管部门和个人信息处理者,共建个人信息处理秩序,以最小的成本实现个人信息处理安全可控的目标。

(二) 穿透式监管策略

复杂的网络生态和高速变化的技术环境需要具备技术属性的监管机制予以回应。^{②7}目前,监管的难点在于个人信息保护机构缺乏必要的技术条件和技术能力而无法进行有效监管。个人信息处理者在算法建模中插入设计者的主观优先级和目标,将他们自身的理念、价值和原则嵌入数据处理、代码编写之中,然后根据这些逻辑开始组织世界,创生出许多无须借助法律的社会控制方式。开发者的价值观负载和内隐偏见将导致自动化决策系统的偏见。数据画像、算法偏见、信息茧房等,其计算逻辑在不同程度上侵蚀了人文精神,甚至形成某种技术主宰、工具主义和技术异化。^{②8}依托数字技术进行的个人信息处理具有隐秘性,但是个人信息监管机构缺乏必要的技术手段而无法触达个人信息的挖掘、分析、共享等后台处理行为,更无法采取有效的管控措施。代码层面的违法使法律的“权利—义务—责任”基本架构无法直接触达个人信息处理活动,需要创新监管方式实现对个人信息处理的穿透式监管,纠正代码对网络社会治理的偏差。

个人信息收集特别是后台处理对于个人信息监管机构而言意味着“黑匣子”,个人信息监管机构很难了解个人信息在后台如何被分析、挖掘、使用、共享等。穿透式监管是针对互联网金融风险专项整治所提出的特定概念。^{②9}穿透式监管能够深度识别互联网业务模式以及基于不同业务模式而进行的个人信息处理行为,使监管更具有针对性。为提升个人信息监管效果,有必要借鉴互联网金融的“穿透式”监管方式,解决个人信息后台处理的“黑匣子”问题。“穿透式”监管体现的“全景敞视主义”机制被细致入微地纳入个人信息处理全过程,具体分析收

^{②6} 黄震、张夏明:《监管沙盒的国际探索进展与中国引进优化研究》,载《金融监管研究》2018年第4期。

^{②7} 崔俊杰:《个人信息安全标准化进路的反思》,载《法学》2020年第7期。

^{②8} 马长山:《数智治理的法治悖论》,载《东方法学》2022年第4期。

^{②9} 2016年10月13日,国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,提出要立足实践,研究解决互联网金融领域暴露出的金融监管体制不适应等问题,需要强化功能监管和综合监管,抓紧明确跨界、交叉型互联网金融产品的“穿透式”监管规则。

集、存储、传输、挖掘、分析、出境、共享以及定向推送等处理行为的风险,在判定具体处理行为的安全隐患和潜在风险的基础上进行相应调整,将个人信息处理风险降至可控和可接受的范围。个人信息监管机构依照《个人信息保护法》制定统一监管框架和具体评估指标,对个人信息处理的各个环节、场景进行实时的监测和评估,并通过一系列措施去遏制或者纠正个人信息处理过程中存在的问题,防控个人信息处理引发的各类风险。个人信息监管机构在形成穿透式监管能力的同时,可以有效缓解有限的监管资源与多点爆发的普遍性违法之间的矛盾。

(三) 监管试验主义

监管沙箱是试验主义治理进路的体现。为实现监管的有效性,监管的时点即监管时机的选择必须恰当,监管不及时会引发监管空白带来的无序及风险,过早地监管又可能扼杀或者扭曲技术发展。^⑩ 监管过早,可能扼杀数字技术创新;监管过晚,无法管控个人信息处理引发的社会风险。监管失灵很大程度上是因为个人信息处理规则滞后。个人信息处理规则的滞后性源于规则制定者的有限理性对数字技术创新及其风险和个人信息处理者以非线性方法对个人信息处理规则做出的反应等无法做出准确的预判。^⑪ 监管实验允许监管机构密切观察试验公司,并确定试验中的业务或操作可能产生的风险。试验性监管过程是一种参与式的规则制定、规则修正和规则执行的过程。监管实验为个人信息处理者创造了一个友好的环境,使他们能够自由地与个人信息监管机构讨论他们所关心的问题,从而加强两者之间的沟通。

个人信息监管机构可以根据从沙箱实验中获得的经验,在试验企业正式进入市场时为其制定理想的监管制度。换言之,监管实验的功能是为监管机构收集更多的数据,以执行数据驱动和基于经验的监管措施。随着监管机构在行业沙箱中与不同类型的机构有更多的合作经验,他们可以根据经验指导和规范个人信息处理行为。监管实验的结果可以起到良好的示范作用。在个人信息监管沙箱中开发后投入运行的解决方案可以发挥示范作用,帮助其他想要开发类似解决方案的公司。此外,监管沙箱的运行实践可以为未来立法提供有价值的参考。通过理解新兴技术原理和运行程序,可以明确个人信息处理的风险和安全隐患,从而明确法律应当采取哪些有效措施明确个人信息处理者的具体义务从而有效保护个人信息安全,上述认识可以为制定前瞻性、有效和务实的法律和政策奠定基础。

四、个人信息监管沙箱的运行逻辑

为消除个人信息安全与数字经济发展之间的冲突,“命令—控制型”监管模式应当转型为个人信息监管部门与个人信息处理者共同维护个人信息处理秩序的协同治理模式。通过个人信息监管沙箱设立受监管的“安全空间”,用于测试需要处理个人信息的技术、产品和服务的安全性和合规性,防控企业在个人信息处理过程中引发的社会风险和个体权益风险,确保创新和个人信息处理以负责任的方式进行。

(一) 监管合作

个人信息监管沙箱是一种合作型的个人信息监管制度。为了促进数字经济发展,监管机

^⑩ 杨东:《监管科技:金融科技的监管挑战与维度建构》,载《中国社会科学》2018年第5期。

^⑪ 参见周仲飞、李敬伟:《金融科技背景下金融监管范式的转变》,载《法学研究》2018年第5期。

构需要审慎监管;为了防控个人信息处理引发的个体安全危机,监管机构又不得不加强监管。合作主义并非简单粗暴地合并或者抵消相互冲突的利益关系,而是通过合作找到安全与发展的平衡点。监管机构通过与被监管机构互动沟通的监管实践,不断改进监管信息不对称、监管能力不足、监管力度过猛的问题,使个人信息处理业务规则及其技术性规则有效地适应数字经济的发展,不至于成为数字技术创新的制度障碍。^③

1. 通过互动优化监管规则。现行个人信息治理标准过于僵化,统一、固定的标准要么让小型个人信息处理者因无法负担高昂的合规成本而无法充分利用个人信息,要么无法完全约束头部互联网平台的个人信息处理活动而使得个人信息权益保护不足。^④在监管沙箱中,监管机构促进但不主导有效治理框架的制定,为个人信息处理行为设定共同标准,开发技术解决方案,并将其应用于沙箱成员和收集用户反馈。个人信息监管沙箱为监管者与个人信息处理者之间搭建了“结构化”且“透明”的沟通与交流方式。通过与监管机构的互动交流,个人信息处理者能够更加清晰地理解规则背后的立法目的和导向,通过与个人信息监管者互动开发的数字产品和服务能够有效地降低试错成本。同时能够在实践中为个人信息处理规则的理解和执行贡献最佳案例,通过建设性参与和监管机构建立基本的信任。个人信息监管机构需要了解个人信息处理者收集使用的个人信息类型、级别,个人信息处理面临的风险及其规则的模糊地带等,同时为个人信息处理者合规提供“定制服务”。

在监管沙箱运行过程中,监管机构应享有灵活的规则制定权,以适应技术创新的挑战和需求。^⑤个人信息监管机构、个人信息处理者和公众在某些情况下可以共同制定规则,帮助个人信息处理者在满足立法目的和法律要求的同时进行创新。为适应数字技术的发展,个人信息监管所依据的众多禁止性规范应当转变为个人信息处理合规指引。与个人信息处理具有密切关系的业务规则和技术性监管规则,如个人信息处理合法、正当、必要、最小原则以及告知同意、个人信息保护影响评估、匿名化等,应当由个人信息监管机构出台明确的合规指引,使规则与技术发展保持同步。通过充分互动和沟通,个人信息处理者帮助监管机构熟悉业务流程、个人信息处理各环节、利用过程等,监管机构制定具有开放性的个人信息处理合规指引。监管沙箱可以让监管机构了解个人信息处理的最新实践,以预测变化并出台有关合规指引,并有可能为未来制定个人信息保护细则提供参考和支撑。

监管机构通过了解实践最新情况用以评估现有监管政策的有效性和不足之处,进而调整个人信息保护法律实施细则和监管政策,在不过度减缓创新步伐的情况下对个人信息进行有效保护。监管机构还可以采用机器可执行的规则在沙箱中实现自动监管,对沙箱成员进行实时监控。以保护个人信息权益为例,监管机构还可以利用分布式账本和生物识别等技术,赋予消费者数据可携性的权利。^⑥在个人信息共享过程中,有了个人信息可移植性和互操作性的基

③ 参见周仲飞、李敬伟:《金融科技背景下金融监管范式的转变》,载《法学研究》2018年第5期。

④ 张新宝:《大型互联网平台企业个人信息保护独立监督机构研究》,载《东方法学》2022年第4期。

⑤ 李有星、柯达:《我国监管沙盒的法律制度构建研究》,载《金融监管研究》2017年第10期。

⑥ Andy Haldane: Speech at the Maxwell Fry Annual Global Finance Lecture: Managing Global Finance as a System, Birmingham University 3, Oct. 29, 2014.

基础设施,用户可以自由决定是否分享自己的个人信息及其分享的内容,个人信息处理者能够开发出更好满足消费者需求的产品和服务。

2. 协商与具体指导。除通过合作优化监管规则外,合作形式还表现为协商或劝服,监管机构尽可能对监管对象采用建议、指导、劝服等方式。^⑤ 个人信息处理合规不再是简单的禁止、应当等义务性规范问题,而是一种技术方案。技术方案是否可行以及是否达到《个人信息保护法》的各项要求需要进行技术检测以及反复验证。以 App 应当设置一键关闭定向推送选项功能为例,对于 App 运营者而言不是简单地在 App 内提供一个关闭按钮的问题,而是真正地从事算法的参数设置为用户提供自然排序的搜索选项。App 运营者是否满足了上述监管要求,既要 App 的具体功能进行检测,也需要专业检测人员和普通用户对 App 进行使用才能验证 App 是否满足监管要求。

就具体指导而言,个人信息监管沙箱通过现场“联合办公”机制实现监管机构对个人信息处理者进行个别指导,共同找到个人信息处理合规的最佳方案。以隐私协议的展示为例,为指导个人信息处理者落实《个人信息保护法》第 17 条规定的“以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知”要求,个人信息监管机构可以就隐私协议的文本结构、具体内容和形式、用语以及展示形式对个人信息处理者提供具体的指导。具体而言:隐私协议应当清晰、准确、完整地描述全部个人信息收集使用行为;隐私协议文本结构应当结构清晰明了,在文首提供个人信息收集类别和目的清单;个人信息处理者提供的产品或服务具备多项业务功能的,应当将业务功能在隐私协议中逐项列出,并明确每项业务功能收集、使用个人信息的类别、目的等通过交互式界面展现隐私协议,采取用户点击、填写、主动勾选等形式,确保用户正确理解掌握隐私协议,保障用户自主选择的权利。

(二) 穿透式监管

个人信息处理过程中具有非常明显的信息不对称性:个人信息被谁收集了,收集了哪些个人信息,特别是个人信息被收集后如何使用以及个人信息提供给谁,对于监管机构和个人信息主体而言是个“黑箱”。穿透式监管的理论基础在于“实质重于形式”的核心原则以及“提升市场透明度”的理念。^⑥ 通过个人信息监管沙箱破解个人信息处理的“黑箱”,提升个人信息处理的透明度,以此防控个人信息处理的各种风险。

1. 破解个人信息处理“黑箱”。数据深度利用和分析的结果是个体“被数字化”,数字技术异化将人的局限性再次放大。数据成为个体交往、互联网服务过程的“主导力量”后,个人自由意志在决策过程中被边缘化,人沦为被数据奴役的对象。个人信息处理者依托自身的技术资源构建了个人信息的处理环境,通过算力、算法决定个人信息利用的广度和深度,通过信息排序和推送影响个体的判断、倾向和选择。因此,个人信息处理合规是代码层面的合规。法律是一种带有导向功能的工具,通过引导个人信息处理者在产品设计、运营过程中依法处理个人信

^⑤ 张红:《监管沙盒及与我国行政法体系的兼容》,载《浙江学刊》2018年第1期。

^⑥ 叶林、吴烨:《金融市场的“穿透式”监管论纲》,载《法学》2017年第12期。

息和履行个人信息安全保障义务,进而使法律在监管科技的发展中起到积极的作用。^③在个人信息监管沙箱中,监管机构可以在设计研发阶段与设计、开发团队进行沟通,对产品或者服务的个人信息处理合规进行指导,以此防范产品或者服务出现代码层面的功能性违法。

个人信息监管沙箱是监管主体“以科技改造监管”的创新和有益尝试,有助于提高个人信息风险监测识别能力,实时地理解个人信息处理各个环节的风险。在个人信息监管沙箱中,个人信息监管机构能够详细地了解新技术解决方案,从而更容易识别潜在风险和现实问题。通过监管沙箱透视后台处理行为,目的是发现其背后的违法处理行为及隐藏的风险。穿透式监管“发现事实”的核心在于突破现行个人信息处理者单方披露的弊端,通过个人信息监管沙箱打开个人信息处理的“黑盒子”,覆盖个人信息处理的整个生命周期,包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除各个环节。通过揭示后台的处理风险,有效约束个人信息处理者的处理行为,减少违法处理和个人信息滥用行为,实现个人信息处理安全可控。

2. 个人信息处理透明化。现行增加透明度的制度设计聚焦于个人信息处理者向个人信息主体披露相关处理情况。个人信息处理者应当通过用户协议、隐私政策等公布其收集和处理个人信息的类型、数量、保存期限以及处理的流程和环节、联系方式等,使个人信息主体能够知道自己的哪些个人信息被收集以及这些信息如何被使用。如果涉及共同处理,应当将共同处理者的名称、地址、联系方式以及共同处理的法律依据和目的、处理数据的类型和数量等进行公示;此外,个人信息处理者应当定期公布自评估报告,将其处理过程中的风险及其处置情况向社会公示。通过告知和公示义务、查询权、备案、数据泄露通报等增加透明度。

阳光是最好的防腐剂。通过增加个人信息处理者在处理过程中的透明度,不仅可以增加个人信息处理者的自我约束感,同时可以降低个人信息处理者与监管机构、个人信息主体之间信息不对称的程度。^④为了有效监督个人信息处理者履行透明度义务,监管部门应当对个人信息处理者的合规情况、风险及其处置情况进行综合评估。对于违法处理行为或者存在安全隐患的个人信息处理行为,个人信息处理者应当向监管部门报告并制定详细的整改措施,监管部门应当对个人信息处理者进行指导监督直至违法处理行为消除以及风险处置措施足以防控处理风险。当公权力介入个人信息处理者的内部经营和个人信息处理活动时,需要谨慎并受到边界的限制,监管机构基于测试产品或者服务的合规性和安全性而获取的商业秘密、企业经营信息、产品源代码等只能用于指导个人信息处理者合规和防控风险的需要,不得用于其他用途。

(三) 技术测试

监管沙箱是一个真实但受到限制的测试环境,监管者在这一环境中测试与了解创新、评估风险,决定被测试的项目是否大面积商用,判定现有监管规则是否需要调整。^⑤技术测试是个人信息监管沙箱的核心,其目的是发现产品或者服务在代码层面是否存在个人信息泄露、违法

^③ 参见徐冬根:《论法律语境下的金融科技与监管科技——以融合与创新为中心展开》,载《东方法学》2019年第6期。

^④ 任龙龙:《论同意不是个人信息处理的正当性基础》,载《政治与法律》2016年第1期。

^⑤ 许多奇:《金融科技的“破坏性创新”本质与监管科技新思路》,载《东方法学》2018年第2期。

处理个人信息的问题。技术测试应贯彻个人信息处理的整个生命周期,重点测试个人信息分析利用、出境等高风险处理行为。在技术测试过程中,测试产品或者服务原则上被豁免执法,监管机构应当对测试过程中知悉的企业的商业秘密、产品源代码等数据履行保密义务。

1. 技术测试方式。进入沙箱测试的产品或者服务不得存在明显侵犯或者威胁个人合法权益的行为,必要时应获得个人信息主体适当的同意,或者依照其他法律依据申请了相关流程。进入个人信息监管沙箱测试的产品或者服务可以是准备上线的创新、前沿项目,也可以是已经上线运行但存在监管不确定性的产品或者服务。监管沙箱可以实现产品设计阶段的个人信息安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用。在产品设计初期便进行管理,对产品各功能设计进行合理干预和标准设定,便于在早期排查出风险隐患。如果申请创新、前沿项目,个人信息监管机构应评估申请者是否有必要使用监管沙箱进行测试,检验其相关的技术、服务或者个人信息处理行为是否需要遵守现行的监管法律。技术测试的目的在于排查个人信息处理风险,同时为进行技术创新的个人信息处理者减轻额外的监管负担,最大限度地激发其进行数字技术创新的积极性。

测试方式原则上采用现场评估和检测的方式。评估和检测不再是简单的源代码披露和审查,^{④①}而是在分析源代码功能的基础上,通过实际使用和操作进行个人信息处理合规测试和风险是否安全可控的实验。实验性监管要求监管者借助模拟实验系统,^{④②}评估个人信息处理风险,检验其是否与现行个人信息保护法律法规存在冲突,是否符合个人信息监管的目标和要求。对于个人信息处理者而言,个人信息监管沙箱不仅可以帮助个人信息处理者无缝对接并嵌套监管政策,而且能及时自测与核验个人信息处理行为是否符合个人信息处理规则和监管要求,提前预测并识别个人信息处理风险。

2. 技术测试内容。个人信息处理风险包括数据泄露的初始风险和数据被不当分析利用的风险。^{④③}目前个人信息监管聚焦于前端的收集问题,但个人信息在后台的分析与利用,特别是数据画像与算法训练,是目前监管机构面对的最大监管难题。考虑数字时代个人信息处理的特殊场景和风险以及平衡产业发展和个人信息安全的需要,个人信息监管沙箱测试的重点应当是利用个人信息进行的识别分析行为。在技术快速迭代和创新面前,个人信息监管者面临着“边学边管”的挑战,这样的挑战对于监管者来说绝非新鲜事,但由于科技公司进入市场的需求量太大,迫使监管者必须快速、频繁地做出决定,所以可能会更加困难。人工智能系统是无限利用数据的分析方法,具有较强的预测和推算能力,给人的隐私或尊严带来新的威胁。^{④④}随着现代数字化技术的发展,借助算法等自动化技术处理手段,可以进行各种网络画像、精准画像的推送,这些都是对个人信息自动化处理的体现。这种个人信息的自动化处理又可能会出

④① 通过披露系统源代码的方式提高透明度,专家也很难弄清楚软件代码执行将产生何种结果,因此检查源代码对于预测计算机程序具体如何运行作用有限。参见杨东:《监管科技:金融科技的监管挑战与维度建构》,载《中国社会科学》2018年第5期。

④② 张永亮:《金融科技监管的原则立场、模式选择与法制革新》,载《法学评论》2020年第5期。

④③ 洪廷青:《我国数据安全法的体系逻辑与实施优化》,载《法学杂志》2023年第2期。

④④ 高富平:《个人信息处理:我国个人信息保护法的规范对象》,载《法商研究》2021年第2期。

现算法歧视、“算法黑箱”、网络画像的滥用等问题。法律并不能通过对个人数据的追踪而进行有效控制,未来个人数据保护的重点应转移到强调个人免受算法的无理监视、秘密操控和不当歧视上来。^{④5} 监管沙箱可以增加算法的透明度,穿透“算法黑箱”避免算法歧视和算法对人的操控,促使群体画像、社会排序中个人信息处理的正当性,在个人信息处理的各种场景下达至数据正义。^{④6}

个人信息出境的安全保障一直是世界难题。为应对个人信息出境给公共安全和国家安全带来的挑战,各国纷纷出台法律法规管控数据出境行为,开展跨境业务的个人信息处理者在监管碎片化面前面临着更大的合规不确定性和成本。^{④7} 尽管许多监管机构已经意识到这个问题,但它们还没有制定出一个有效的解决方案。个人信息处理者在存储和处理其数据时,可能需要遵守不同的要求。为了解决监管碎片化问题,个人信息监管机构需要积极参与外国监管机构的跨境合作以及与其他行业监管机构的跨行业合作。通过监管沙箱机制开展跨境合作,在应对数据跨境引发的公共安全和国家安全威胁的同时,可以有效降低个人信息处理者的合规成本,监管机构也可以通过合作提升自身的监管能力。

3. 执法豁免。在一个受控的环境里激励数字技术创新,通过观察、试错、交流,个人信息处理者和监管机构可以找到个人信息处理及其监管的最优方案,特别是考虑不同行业领域以及不同业务的特殊性,探寻个人信息合规的个性化方案。个人信息监管沙箱具有一定程度的非正式性和灵活性。虽然不能容忍明显或严重的违法行为,但对沙箱测试的监督意味着允许一定程度的监管放松和实验性的合规过程。在测试期间且未正式上线之前,测试产品或者服务原则上被豁免执法,特别是个人信息处理者不知道其产品或者服务违反《个人信息保护法》时,在监管沙箱中的测试行为不会立即导致监管行动,但个人信息处理者应当就个人信息处理行为与个人信息监管机构保持合作与对话。

在沙箱运行过程中,个人信息处理行为完全暴露在监管机构监督之下,沙箱中披露的信息仅在特殊情况下用作执法行动的依据,如在存在欺骗或虚假陈述或不遵守参与条件的情况下。如果在线上删除或者修改了存在违法收集使用个人信息的功能服务,仅在监督测试阶段出现不合规,不会引发执法行为;如果没有进一步的调查,则不遵守个人信息监管机构整改建议的行为将不会成为执行行为的理由。需要明确的是,执法豁免的通常是行政责任特别是罚款等,责令停止违法行为以及个人信息处理者履行其他补救义务等不在豁免的范围。如发生个人信息泄露,个人信息处理者应当依照《个人信息保护法》的规定履行通报义务。依照安全可控的原则,技术测试不是完全消除风险,即绝对安全观,而是将风险控制在可控范围内。如果经测试的产品或者服务在运营过程中出现违法收集使用个人信息或者发生安全事件时,应当依照《个人信息保护法》的规定承担行政责任、民事责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

④5 梅夏英:《在分享和控制之间 数据保护的私法局限和公共秩序构建》,载《中外法学》2019年第4期。

④6 许可:《数据要素市场的法律建构:模式比较与中国路径》,载《法学杂志》2023年第6期。

④7 W. Kuan Hon, Christopher Millard: Use by Banks of Cloud Computing: An Empirical Study, Queen Mary U. of London, Sch. of L. Legal Stud. Res. Paper, 2016.

五、结语

数字时代,商业模式的创新和技术进步使得个人信息治理体系必须以一种积极灵活的态度去面对层出不穷的新问题。数字技术的突破性创新要求监管者及时识别个人信息处理模式、方法的变化,并考虑这些变化对个人信息处理风险的结构性影响。个人信息监管沙箱对个人信息监管将是一个方法论意义上的深刻转型。个人信息监管沙箱是基于数字技术引发个人信息处理风险泛化的现实而提出的个人信息监管新范式,是从个人信息监管顶层设计层面,对个人信息监管理念、体制和方法进行重构。个人信息监管沙箱是推进数字经济发展行稳致远的关键工具之一。对于监管者而言,个人信息监管沙箱有利于监管者构建一个以个人信息安全可控为基础的更为合理的监管框架。个人信息监管沙箱在明确个人信息监管边界的基础上,与个人信息安全审查共同构建了一套刚柔并济的“威慑式+合作式”的监管制度。

Theoretical Justification and Institutional Construction of the Personal Information Regulatory Sandbox

Cui Congcong

Abstract: Big data, with personal information as its main content, is the core production element of the digital economy. At present, the main means of administrative regulation of personal information is special governance. The top-down control regulatory path relied upon for special enforcement of personal information has caused many problems, such as tension between insufficient regulatory and innovation and even inhibiting technological innovation. The focus of special governance of personal information is on illegal processing behaviors such as excess collection, compulsory claim and excessive authorization. Although it can prevent and control the risk of leakage and misuse caused by large-scale processing of personal information, it forms an institutional constraint on the development of the digital economy, which is bound to cause structural waste and shortage of data resources. The prevention and control of personal information processing risks through special governance has highlighted the dilemma of the campaign-style regulation paradigm. It is urgent to form a systematic paradigm for administrative regulation of personal information that adapts to the development of the digital economy. The personal information regulatory sandbox based on the concepts of regulatory cooperation, penetrating regulation and regulatory experimentation is a key variable inducing the transformation of the paradigm of administrative regulation of personal information. It can effectively balance the conflict between the development of the digital economy and the security of personal information, and should be used as a regulatory tool for personal information in the future.

Keywords: personal information regulatory sandbox; digital economy; penetrating regulation; cooperative supervision

(责任编辑:刘宇琼)